

De positie van de duomoeder in de erkenningsprocedure

EB 2023/49

1. Inleiding

In dit artikel staat de juridische positie van de duomoeder centraal. In geval van uiteengaan van de duomoeder en de geboortemoeder lijkt de positie van de duomoeder zwakker ten opzichte van de positie van de biologische vader. Dit ondanks de doelstelling van de wetgever met de 'Wet Lesbisch ouderschap' om de positie van kinderen geboren in lesbische relaties zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met die van kinderen in heteroseksuele relaties. De wetgever achtte het van doorslaggevend belang om uit te gaan van de feitelijke opgroei- en opvoedingssituatie van het kind als basis voor het juridisch ouderschap.² Maar is die doelstelling ook gehaald?

Wij bespreken achtereenvolgens de regeling van de vervangende toestemming voor de erkenning, de positie van de verwekker/biologische vader met family life en de positie van de duomoeder. Vervolgens bespreken wij hoe verzoeken betreffende vervangende toestemming worden beoordeeld in de rechtspraak, behandelen we de aanbevelingen uit de literatuur en komen wij tot conclusies en aanbevelingen.

2. Biologisch-, genetisch-, juridisch- en sociaal ouderschap

Allereerst is het wenselijk om kort stil te staan bij de begrippen biologisch-, genetisch-, juridisch- en sociaal ouderschap.

Op grond van artikel 1:198 lid 1 sub a BW is de juridische moeder van het kind de vrouw uit wie het kind is geboren. Wij noemen deze juridische moeder verder 'de geboortemoeder'. Als de geboortemoeder is gehuwd (of in een geregistreerd partnerschap verbonden), is haar echtgenoot (geregistreerde partner) als dat een man is, altijd de juridische vader van het kind. Is de geboortemoeder gehuwd met een vrouw, dan is zij de juridische ouder van het kind als bij de geboorteaangifte een zogenoemde onbekendheidsverklaring betreffende de identiteit van de donor is overgelegd (art. 1:198 lid 1 onder b BW). Is er naast de geboortemoeder geen tweede juridische ouder, dan kan het kind worden erkend.

Uit artikel 1:204 lid 3 BW volgt dat de persoon die het kind wil erkennen en hiervoor geen toestemming krijgt van de

geboortemoeder, vervangende toestemming kan vragen aan de rechtbank mits die persoon de verwekker (sub a) of de biologische vader met family life is (sub b). In beide gevallen gaat het hier om een man met biologische verwantschap.

De vrouwelijke partner van de geboortemoeder én de mannelijke partner niet zijnde de verwekker of biologische vader met family life³ kunnen op grond van artikel 1:204 lid 4 BW vervangende toestemming verzoeken om te mogen erkennen. Zij dienen dan te kwalificeren als levensgezel van de geboortemoeder die heeft ingestemd met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad. De vervangende toestemming wordt slechts verleend als dit in het belang van het kind is. Zolang de vrouwelijke partner van de geboortemoeder niet de status van juridisch ouder heeft, is zij feitelijk slechts een zogenoemde sociale ouder. De vrouwelijke partner van de geboortemoeder wordt verder, ongeacht of zij wel of niet de status van juridische ouder heeft, 'de duomoeder' genoemd.

In de wet ontbreekt een regeling voor de genetische moeder met family life. De vrouw die haar eikel doneert, wordt niet van rechtswege moeder.⁴ Anders dan de genetische vader, zijnde de verwekker of de biologische vader met family life, kan de genetische moeder geen beroep doen op artikel 1:204 lid 3 BW maar slechts op artikel 1:204 BW. Zij kwalificeert immers niet als 'verwekker' of 'biologische vader'. De genetische moeder wordt dan volgens de wet gelijk behandeld als de instemmende levensgezel, terwijl zij in tegenstelling tot de instemmende levensgezel wél een genetische band heeft met het kind. Het gaat deze bijdrage te buiten om hier nader bij stil te staan, maar het kan verdedigd worden dat de genetische moeder in het licht van artikel 8 jo. 14 EVRM gelijk zou moeten worden behandeld met de genetische vader en een rechtsingang zou moeten krijgen op grond van artikel 1:204 lid 3 BW.

3. Vervangende toestemming tot erkenning van de verwekker/biologische vader met family life

De verwekker/biologische vader met family life die zoekt om vervangende toestemming te verkrijgen om de minderjarige te erkennen, heeft in gerechtelijke procedures een sterke positie. De toestemming wordt hem slechts onthouden wanneer dit de belangen van de geboortemoeder

¹ Mevrouw mr. I. (Ilse) van Dijk-van Oosterhout en mevrouw mr. N. (Nickie) Groen zijn beiden werkzaam als advocaat(-mediator) bij SCG Advocaten.

² Kamerstukken II 2011/12, 33032, nr. 3, p. 1, 4 en 5. Zie ook E.T.P. Merckx, *Geboren met twee moeders* (masterscriptie), 2014, p. 22.

³ Dit is vaak de mannelijke partner van de moeder die instemt met kunstmatige bevruchting.

⁴ In dit artikel beperken wij ons tot de vervangende toestemming tot erkenning van de genetische moeder met family life. Wij bespreken niet de mogelijkheid dat een eikel wordt gebruikt bij een draagmoederschapsconstructie.

bij een ongestoorde verhouding met het kind schaadt of wanneer een evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrang is. Daarbij is de verwekker bij een verzoek vervangende toestemming tot erkenning direct ontvankelijk. De spermadonor/biologische vader niet zijnde de verwekker zal om ontvankelijk te zijn eerst moeten aantonen dat er sprake is van family life tussen hem en het kind. Dat kan problematisch zijn als tussen hem en het kind nimmer contact is geweest. In de rechtspraak blijkt echter dat ingeval de spermadonor een beroep doet op de bedoeling om family life te gaan hebben (*intended family life*) hij al snel ontvankelijk wordt verklaard.

Wil een geboortemoeder de erkenning door de verwekker/biologische vader met family life tegenhouden dan moet zij van goeden huize komen. Een zekere emotionele weerstand van de moeder is op zichzelf niet voldoende (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1320). Ook weerstand van een geboortemoeder vanwege de juridische mogelijkheden die erkenning met zich meebrengt, zoals omgang en gezag, staan daar los van (Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 januari 2021, ECLI:NL:GHSE:2021:231). Dit kan anders liggen wanneer de weerstand van de geboortemoeder negatieve gevolgen heeft voor het kind. Enkele voorbeelden uit de jurisprudentie waarin een verzoek op grond van lid 3 werd afgewezen zijn met name te vinden in de sfeer van ernstig huishelijk geweld (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:5781, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 januari 2022, ECLI:NL:GHSE:2022:195, Rechtbank Noord-Holland 3 maart 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:1803, Gerechtshof Amsterdam 21 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1812). De positie van de verwekker en de biologische vader met family life is aldus erg sterk. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt het verzoek niet toegewezen.

4. De juridische positie van de duomoeder

De juridische positie van de duomoeder is complexer. Sinds de inwerkingtreding van de 'Wet Lesbisch ouderschap' per 1 april 2014 is het voor twee vrouwen echter een stuk gemakkelijker geworden om allebei juridisch ouder van een kind te worden.⁵ Adoptie door de duomoeder is sedertdien niet meer de enige manier om juridisch ouder van het kind te worden. De duomoeder kan op de volgende manieren juridisch ouder worden van het kind:

- als zij op het tijdstip van de geboorte van het kind gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder, terwijl het kind is verwekt door kunstmatige donorbevruchting met behulp van een onbekende donor die geregistreerd is in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en er wordt beschikt over een verklaring van de Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting (hierna: de Stichting) ter bevestiging hiervan die moet worden

overgelegd ten tijde van de geboorteaangifte van het kind;

- door erkenning;
- door de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap;
- door adoptie.

Dit betekent dat de duomoeder sinds 1 april 2014 zonder dat een procedure bij de rechter nodig is, juridisch moeder van het kind kan worden.⁶ Dit is sinds die datum via het afstammingsrecht geregeld. Hiermee is getracht recht te doen aan de gelijke behandeling van paren met een kinderwens in een heteroseksuele relatie en paren met een kinderwens in een lesbische relatie.

Toch is van gelijke behandeling geen sprake. Zo is een groot verschil dat anders dan bij man-vrouwrelaties bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap de mannelijke partner van de geboortemoeder zonder meer de juridische vader is.⁷ Bij twee vrouwen is hiervoor vereist dat sprake is van een onbekende donor (en over een verklaring van de Stichting wordt beschikt die bij de aangifte van geboorte moet worden overgelegd). Bij een bekende donor zal de duomoeder de weg van de erkenning moeten volgen en dus de toestemming van de moeder nodig hebben en van het kind indien het 12 jaar of ouder is of van het kind alleen indien het 16 jaar of ouder is.⁸ Vanwege de presumptie van het vaderschap wordt dit verschil gerechtvaardigd door de wetgever, terwijl de duomoeder ook de biologische moeder van het kind kan zijn door eiceldonatie.⁹ En dit terwijl ook niet in alle gevallen de gehuwde of geregistreerde mannelijke partner de verwekker is van het kind.

Ook dit wordt door de wetgever gerechtvaardigd vanuit de gedachte dat in geval er sprake is van een onbekende donor, deze donor daarmee aangeeft geen enkele rol te willen vervullen in het leven van het kind.¹⁰ Dit onderscheid kan door vrouwelijke partners als oneerlijk en ongelijk worden ervaren. Is dit verschil uit te leggen in het geval er sprake is van een bekende donor waarvan het kind niets te verwachten heeft? De vraag kan worden gesteld of hier geen verboden onderscheid naar seksuele geaardheid wordt gemaakt.

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft aan dit aspect ook aandacht besteed in haar rapport: *Kind en ouders in de 21^e eeuw*, uit 2016. De Staatscommissie verwijst naar het feit dat hoewel voor twee moeders vaststaat dat er een derde in het spel is geweest, dit ook geldt voor de situatie binnen relaties van ongelijk geslacht waarin gebruik is gemaakt van donorzaad. In die situatie wordt geen bewijs van onbekendheid van de donor verlangd voor het van rechtswege

⁵ Wet van 25 november 2013, *Stb.* 2013, 480.

⁶ Voor inwerkingtreding van de Wet Lesbisch ouderschap kon de duomoeder enkel juridisch ouder worden door adoptie. Dit was mogelijk met in-gang van 1 april 2001.

⁷ Artikel 1:199 sub a BW.

⁸ Artikel 1:204 lid 1 sub c BW.

⁹ *Kamerstukken II* 2011/12, 33032, nr. 3, p. 7.

¹⁰ *Kamerstukken II* 2011/12, 33032, nr. 3, p. 7.

ontstaan van het ouderschap. De Staatscommissie heeft dan ook aanbevolen het vereiste van het overleggen van een onbekendheidsverklaring te schrappen. Dit zou dan betekenen dat als het kind wordt geboren binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen, het kind automatisch beide vrouwen als juridische moeder zou krijgen, net zoals dit het geval is bij de geboorte van het kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw. Kinderen komen dan automatisch in familie-rechtelijke betrekking te staan tot beide moeders ongeacht of sprake is van een bekende dan wel onbekende donor.¹¹ Deze aanbeveling heeft tot op heden nog niet tot een wetswijziging zoals aanbevolen door de Staatscommissie geleid, maar dit zou in onze visie wel wenselijk zijn.

5. Vervangende toestemming tot erkenning door de duomoeder

Voor de erkenning¹² van het kind heeft de duomoeder de toestemming van de geboortemoeder nodig en die van het kind van 12 jaar of ouder. Indien het kind 16 jaar of ouder is, heeft de duomoeder alleen de toestemming van het kind zelf nodig. Deze toestemming wordt in de meeste gevallen tijdens de relatie verleend. In sommige gevallen wordt die niet verleend. In de meeste gevallen waarin de geboortemoeder haar toestemming weigert, hebben de vrouwelijke partners hun relatie verbroken. De duomoeder zal dan de weg van het verzoeken van de vervangende toestemming moeten volgen nu de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap enkel door de geboortemoeder of het kind kunnen worden verzocht.¹³

Op grond van artikel 1:204 lid 4 BW kan de rechtbank vervangende toestemming voor de erkenning verlenen indien:

- de duomoeder, als levensgezel van de moeder, heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad;
- de erkenning in het belang van het kind is.

6. Jurisprudentie-onderzoek

Hoe stevig is de positie van de vrouwelijke partner van de geboortemoeder nu inmiddels? We bespreken hieronder de uitspraken die ons opvielen. Daar waar het echter gaat om een verzoek om vervangende toestemming op grond van artikel 1:204 lid 4 BW is de jurisprudentie niet zo eenduidig. Wij lopen de rechtspraak aan de hand van de bovenstaande vereisten langs.

a) Wie is de levensgezel van de geboortemoeder?

Wat moet worden verstaan onder het begrip 'levensgezel' volgt niet uit de wet. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch legde op 21 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2697, het begrip nader uit in het kader van een verzoek tot vervangende toestemming van de duomoeder. In die zaak oordeelde het hof dat geen sprake was van het zijn van levensgezel van de duomoeder. De relatie had een ongelijk karakter doordat de duomoeder de voormalig ambulant hulpverlenster van de moeder was, terwijl de geboortemoeder bij het aangaan van de relatie vanwege haar psychische en psychiatrische problematiek zeer zwak was in geestelijk opzicht. Er was sprake van een afhankelijkheidsrelatie en in die zin week deze relatie af van een gebruikelijke relatie tussen echtgenoten en geregistreerde partners. Bovendien ontbrak de financiële verwevenheid. Het hof was van oordeel dat wel enige vorm van economische verwevenheid dan wel van financiële afspraken met betrekking tot de huishouding nodig is om het zijn van levensgezel aan te kunnen nemen.

Het Gerechtshof Amsterdam kwam wel tot de conclusie dat sprake was van het voldoen aan het criterium: levensgezel. In deze uitspraak van 15 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:394, in het kader van een verzoek van de moeder tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap¹⁴ van de man die als levensgezel had ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kon hebben gehad.

Bij de vraag of er sprake is van een 'levensgezel' zijn volgens het hof¹⁵ de volgende aspecten van belang:

1. is er sprake van een gemeenschappelijke huishouding;
2. de duur van de gemeenschappelijke huishouding;
3. of er een relatie van affectieve aard is, en met name;
4. of betrokkenen kennelijk uitgaan van een nauwe lotsverbondenheid.

Een nauwe persoonlijke betrekking van een zekere hechtheid is echter doorslaggevend. Volgens het hof moet het gaan om een relatie die qua hechtheid vergelijkbaar is met die tussen echtgenoten of geregistreerd partners. Deze is niet per se met het enkele feit van het samenwonen gegeven en vereist ook niet per se dat betrokkenen met elkaar samenwonen (*Kamerstukken II* 2002/03, 28484, nr. 5, p. 5).

De voornoemde vier aspecten hoeven niet alle vier aanwezig te zijn, maar kunnen een rol spelen bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking van een zekere hechtheid die qua hechtheid vergelijkbaar is met die tussen echtgenoten en geregistreerd partners, aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van 1 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:107 in rov. 3.2.2.

De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam geeft hiermee helder weer wat een duomoeder moet stellen en bij betwisting bewijzen om te kwalificeren als levensgezel.

11 Rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap, *Kind en ouders in de 21^e eeuw*, p. 405 en 406.

12 De Wet Lesbisch ouderschap kent geen overgangsregeling. De wet heeft onmiddellijke werking op het tijdstip van inwerkingtreding. Dat betekent dat de erkenning ook kan plaatsvinden ten aanzien van kinderen die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn geboren.

13 Artikel 1:207 lid 1 sub a en b BW.

14 Artikel 1:207 BW.

15 Rov. 5.10.

- b) Heeft de levensgezel ingestemd met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad?

Voorts is vereist dat de levensgezel van de geboortemoeder ook heeft ingestemd met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad.¹⁶ In de rechtspraak wordt over het vereiste van instemming het navolgende opgemerkt.

Het Gerechtshof Den Haag 17 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2031, kreeg de vraag op welk moment de duomoeder moet instemmen. In deze zaak ging het om een geboortemoeder die zwanger raakte uit een overspelige affaire met de neef van de duomoeder. De duomoeder verzocht na het verbreken van de relatie tussen partijen alsnog om vervangende toestemming om de minderjarige te mogen erkennen. Het hof moest antwoord geven op de vraag of ook achteraf kan worden ingestemd met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad. Het hof kwam tot het oordeel dat de duomoeder op het moment dat de geboortemoeder zwanger raakte niet had ingestemd met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad. De omstandigheid dat partijen nadien hun relatie hadden voorgezet en ook enige tijd samen voor de minderjarige hadden gezorgd, maakte dat niet anders. Daarbij woog het hof mee dat de duomoeder pas enkele maanden nadat de geboortemoeder zwanger was geworden van de zwangerschap op de hoogte raakte. Bovendien hoorde zij pas enige tijd na de geboorte van de minderjarige wie de verwekker was.

Het hof vernietigde vervolgens wel de beschikking in eerste aanleg, ondanks dat daarin ook geen vervangende toestemming was verleend, omdat de rechtbank ten onrechte het verzoek van de duomoeder had afgewezen. Juiste lezing van artikel 1:204 lid 4 BW brengt mee dat de duomoeder niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard in haar verzoek. Dat doet het hof na vernietiging alsnog.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10411,¹⁷ moest beoordelen wat wordt verstaan onder instemming met "de daad die de verwekking tot gevolg heeft". In deze zaak hadden partijen hun relatie kort voordat de geboortemoeder via een ivf-traject zwanger raakte, geformaliseerd. De geboortemoeder had voordien al een kinderwens. Het hof was, anders dan de Rechtbank Overijssel¹⁸ van oordeel dat de daad van verwekking meer omvat dan de enkele bevruchting van de eicellen of de terugplaatsing van de embryo's. Het hof knoopte daarvoor aan bij artikel 1 aanhef en sub c van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting¹⁹ waaruit volgt dat een kunstmatige

donorbevruchting uit (meerdere) handelingen bestaat die zijn gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand komen van een zwangerschap. Het hof woog mee dat de geboortemoeder zelfstandig een lang voortraject had gevolgd, eerst zelf had gezocht naar een donor, vervolgens meerdere pogingen had gedaan om via KID-behandelingen zwanger te raken en uiteindelijk in het kader van het ivf-traject zwanger was geraakt. Het hof concludeerde uit deze feitelijkeheden rondom de zwangerschap dat de duomoeder geen invloed had gehad op de beslissing van de geboortemoeder om zwanger te worden. Toen de duomoeder eenmaal betrokken raakte, was het behandeltraject al in een vergevorderd stadium. Het hof was niet gebleken dat partijen met elkaar hadden gesproken over de zwangerschap en dat de duomoeder met de zwangerschap van de geboortemoeder had ingestemd anders dan dat zij passief meebewoog en de zwangerschap duldde. Het bestaan van de relatie tussen de geboortemoeder en de duomoeder op het moment van de bevruchting en de terugplaatsing was, aldus het hof, gelet op de gegeven omstandigheden, onvoldoende om daaruit de instemming als bedoeld in artikel 1:204 lid 4 BW af te leiden. De door de duomoeder aangevoerde omstandigheden dat zij zich tijdens de zwangerschap als moeder heeft gedragen, onder meer door samen met de geboortemoeder te kiezen voor de naam van de minderjarige en op het geboortekaartje vermeld te staan als moeder, deed daar aldus het hof niet aan af omdat dit omstandigheden waren die na de totstandkoming van de zwangerschap hebben plaatsgevonden. Dit is eenzelfde overweging als in de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, voornoemd, waarin het hof oordeelde dat het voortzetten van de relatie en het zorgen voor de minderjarige na haar geboorte voor de vraag of de duomoeder kwalificeert als instemmende levensgezel niet uitmaakt. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat geen sprake was van instemming met de daad die verwekking tot gevolg kan hebben gehad, vernietigde de beslissing van de rechtbank en wees het verzoek van de duomoeder alsnog af.²⁰

Deze uitspraak is opvallend. De vraag kan worden gesteld of de uitleg van het hof omtrent "een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad" niet te ruim is. Het hof knoopt daarvoor aan bij de uitleg uit de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en weegt het gehele voortraject mee. Het hof vindt dat de duomoeder op meer momenten dan enkel de werkelijke bevruchting (punctie en terugplaatsing) had moeten instemmen. In de Memorie van Toelichting bij de Wet Lesbisch ouderschap werd echter ten aanzien van het vraagstuk omtrent een voor de geboorte van het kind overleden duomoeder aangegeven dat wordt verondersteld dat de duomoeder die betrokken is geweest bij de beslissing over de kunstmatige donorbevruchting van de moeder de moeder van het kind is als zij op het tijdstip waarop de kunstmatige bevruchting is verricht de echtgenoot was van

16 Hoewel in uitspraken ook dikwijls eerst om proceseconomische redenen een van de andere wettelijke vereisten wordt besproken.

17 In dit dossier is mr. Nickie Groen (medeauteur van dit artikel) betrokken geweest als advocaat.

18 Deze uitspraak wordt verderop in dit artikel besproken.

19 *Kamerstukken II 2020/21, 35870, Wijziging van Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan.*

20 Met het komen tot een afwijzing na de constatering dat geen sprake was van instemming met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad, wijkt deze uitspraak dus af van zie de eerdergenoemde uitspraak van het Gerechtshof Den Haag 17 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2031, waarin het hof de verzoekster niet-ontvankelijk verklaarde.

de geboortemoeder. Dit tijdstip is blijkens de Memorie van Toelichting tot op de dag nauwkeurig vast te stellen en doet daardoor zoveel mogelijk recht aan de feitelijke situatie.²¹ Dat strookt niet met de visie van het hof dat die toestemming op het gehele voortraject moet zien. Daarbij lijkt het hof in deze uitspraak uit te gaan van instemming met "de daad" die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad, terwijl de wetgever uitgaat van "een daad". Het hof beperkt daarmee de mogelijkheid voor deze sociale ouder, terwijl de gedachte achter de wet was dat een kind de mogelijkheid moet krijgen om in een familierechtelijke betrekking komen te staan met een persoon met wie hij een vanzelfsprekende relatie heeft, de sociale ouder. In dat kader vragen wij ons af of deze uitspraak ook als zodanig was geweest als het andersom was geweest en de geboortemoeder gerechtelijke vaststelling van het ouderschap had gevraagd of in een later stadium vernietiging van de erkenning (Rechtbank Gelderland 20 april 2016, ECLI:NL:RBGE:2016:3647, PRG 2016/225 en Rechtbank Rotterdam 24 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:12653).

- c) Is het verlenen van vervangende toestemming in het belang van de minderjarige?

Kwalificeert verzoekster als instemmende levensgezel en is zij over die ontvankelijkheidsdrempel heen, dan komt de inhoudelijke beoordeling van het verzoek aan de orde. Beoordeeld wordt dan of het verzoek in het belang is van de minderjarige.

In Rechtbank Noord-Nederland 30 juli 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3359, was tussen partijen in geschil of de duomoeder kon worden aangemerkt als instemmende levensgezel. De duomoeder stelde dat partijen vanaf 2007 tot november 2018 een affectieve relatie hadden gehad. De geboortemoeder stelde echter dat partijen slechts een vriendschappelijke relatie hadden en dat de geboortemoeder bewust had gekozen voor het alleenstaand ouderschap. De rechtbank kwam echter niet toe aan beantwoording van die vraag omdat de rechtbank zich 'om proceseconomische redenen' eerst afvroeg of het in het belang van het kind zou zijn dat de duomoeder het erkende. Daarbij woog de rechtbank mee dat partijen een zeer ernstig verstoorde verhouding hadden, zij niet met elkaar hadden samengewoond, niet duidelijk was geworden dat de duomoeder ook een verzorgende rol vervulde in het leven van de minderjarige zoals een ouder dat wel had gedaan. De Raad voor de Kinderbescherming werd om die reden verzocht eerst te onderzoeken of het in het belang van de minderjarige zou zijn dat de duomoeder het erkende. De rechtbank gaf aan als dat het geval zou zijn, zij zich verder zou beraden op de vraag of uit de feiten en omstandigheden ook volgt dat de duomoeder de instemmende levensgezel is.²²

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8783, beoordeelde een jaar eerder ook of het verlenen van vervangende toestemming in het belang van de minderjarige zou zijn. Tussen deze partijen stond wel vast dat sprake was geweest van een affectieve relatie en dat de duomoeder had ingestemd met de daad die de verwekking van beide kinderen tot gevolg kon hebben gehad. Bovendien was in deze zaak het eerste kind van partijen, geboren in 2014, ook door de duomoeder erkend. De duomoeder verzocht vervangende toestemming om het tweede kind dat nog tijdens de relatie was geboren, te mogen erkennen. De rechtbank verleende de duomoeder vervangende toestemming. Het hof kwam echter tot een ander oordeel. Uit de uitspraak zelf blijkt niet waar het in deze zaak tussen partijen mis is gegaan. Wel is te lezen dat partijen zich vanwege de complexe verstandhouding hadden gewend tot een instantie voor omgangsbegeleiding. Het lukte hen echter niet om nader tot elkaar te komen en hun standpunten leken steeds verder uiteen te lopen. Om die reden adviseerde de Raad voor de Kinderbescherming de vervangende toestemming voor de erkenning af te wijzen. Dat advies werd ook onderschreven door de bijzondere curator. Er was geen positieve verandering te zien in de moeizame verstandhouding en de voortdurende strijd tussen de duomoeder en de geboortemoeder. Het hof verwachtte niet dat hierin op termijn verbetering zou komen. Gelet op de persoonlijke problematiek van de duomoeder (alexithymie)²³ zag het hof geen perspectief op goed ouderschap. Daarbij woog het hof ook mee dat de minderjarige kwetsbaar was en behoefte had aan rust in de situatie. Het hof vernietigde om die reden de beschikking van de rechtbank en wees het verzoek van de vrouw tot vervangende toestemming tot erkenning af.²⁴

Deze beslissing bevreemdt op zichzelf niet. De wetgever heeft er immers voor gekozen om in de wet op te nemen dat, in het belang van het kind, een verzoek tot vervangende toestemming erkenning kan worden afgewezen. Echter, daar waar sprake is van een complexe verstandhouding verdient het onzes inziens wel aandacht dat die verstandhouding op zichzelf een oneigenlijk middel kan zijn om de duomoeder buiten de deur te houden. Het bewust laten verslechteren van de relatie kan dan gebruikt worden om de vervangende toestemming in het belang van het kind te onthouden. In dit geval lijkt de verslechterde verstandhouding niet de enige zorg waarom de erkenning niet in het belang van het kind zou zijn. Echter, het gebruiken van de verhouding tussen partijen voor het afwijzen van een verzoek, moet in onze optiek zorgvuldig worden meegewogen en niet uitsluitend een reden zijn om in het belang van de minderjarige te komen tot een niet-ontvankelijkverklaring.

21 Kamerstukken II 2011/12, 33032, nr. 3, p. 14 en 15.

22 Het vervolg van deze zaak is niet gepubliceerd. Van de handelend advocaat in eerste aanleg begrepen wij dat het verzoek na het raadsonderzoek in eerste aanleg is afgewezen.

23 Een psychische stoornis waarbij het affectief en cognitief functioneren wordt aangetast. Iemand is niet in staat de eigen emoties te bevatten en er kan een beperking ontstaan in de mogelijkheid tot fantaseren.

24 Dit is niet correct en had een niet-ontvankelijkheid moeten zijn. Zie voornoemd bij de uitspraak Gerechtshof Den Haag 17 juli 2019, ECLI:NL:GHDAA:2019:2031.

Dat een verstoorde verhouding niet doorslaggevend hoeft te zijn bij de belangenafweging, oordeelde de Rechtbank Noord-Holland eerder in een uitspraak van 12 juli 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:5743. Het ging hier over twee met elkaar gehuwde vrouwen. Tijdens hun huwelijk zijn met instemming van de duomoeder uit de geboortemoeder twee kinderen geboren. Ten tijde van de geboorte van de kinderen bestond de mogelijkheid tot erkenning door de duomoeder nog niet.²⁵ De duomoeder heeft de kinderen ook niet geadopteerd. Het huwelijk van partijen werd vervolgens ontbonden door echtscheiding en partijen hadden sinds de echtscheiding een ernstig verstoorde verhouding. De oudste minderjarige had geen contact meer met de duomoeder en beide kinderen waren onder toezichtstelling gesteld. De duomoeder verzocht om haar vervangende toestemming te verlenen om de minderjarigen te erkennen. Tijdens de reeds lopende procedure had de geboortemoeder echter haar nieuwe vriend reeds toestemming gegeven om de kinderen te erkennen en is naamskeuze gedaan voor de geslachtsnaam van de nieuwe vriend.

De rechtbank besprak hier eerst de vraag hoe de latere erkenning door de vriend van de geboortemoeder moest worden beschouwd, nu er slechts twee juridische ouders kunnen zijn. Daarbij verwees de rechtbank naar de jurisprudentie van de Hoge Raad van 31 mei 2002, ECLI:HR:2002:AE0745, NJ 2002/470 en 30 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3196. Daaruit volgt dat vanaf het moment waarop een verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming bij de rechtbank is ingediend en totdat daarop definitief is beslist, de door de moeder verleende toestemming aan een derde slechts voorwaardelijk is.

Vervolgens toetste de rechtbank aan het criterium als opgenomen in artikel 1:204 lid 4 BW. De belangenafweging resulteerde, ondanks de zorgelijke situatie van de kinderen en de ernstig verstoorde verhouding tussen de ex-echtgenotes in het verlenen van vervangende toestemming. Daarbij was de rechtbank van oordeel dat het vastleggen van het juridisch ouderschap van de duomoeder in het belang van de minderjarigen was. *“Het sluit aan bij hun afstamming en geeft blijk van hun ontstaansgeschiedenis. Dat [minderjarige] op dit moment niet open staat voor contact met [naam] doet daar niet aan afen staat los van zijn belang bij het hebben van [naam] als juridisch ouder. De rechtbank merkt daarbij op dat het feit dat [minderjarige] dit niet wil, niet betekent dat het daarmee ook niet in zijn belang zou zijn. Dat [minderjarige] het in de huidige situatie fijn vindt dat de man een vader voor hem is, is een waardevolle aanvulling in het leven van zowel [minderjarige] als [minderjarige]. Echter, of de erkenning door de man, die niet de biologische ouder is van de minderjarigen, in hun belang kan worden geacht, kan door [minderjarige] niet worden beoordeeld.”* Aan de duomoeder werd vervangende

toestemming tot erkenning verleend en de erkenning die was gedaan door de nieuwe vriend van de moeder moest worden doorgehaald.

Van belang voor de duomoeder is dat ook het Hof Arnhem-Leeuwarden bij uitspraak van 10 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:5780, oordeelde dat het leerstuk van de voorwaardelijke toestemming ook geldt in geval van duomoederschap. De toestemming aan de derde heeft alleen gevolgen indien de eerder verzochte toestemming bij een definitief geworden rechterlijke uitspraak is geweigerd en is anders nietig.

In de uitspraak die door het Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10411, werd vernietigd, kwam de Rechtbank Overijssel 3 februari 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:357,²⁶ die de duomoeder had gekwalificeerd als ‘instemmende levensgezel’ toe aan een inhoudelijke beoordeling. De rechtbank oordeelde dat het verlenen van vervangende toestemming in het belang van de minderjarige was. De rechtbank achtte het in het belang van haar identiteitsontwikkeling dat zij zou weten uit welke relatie zij is geboren en hoe de familieverhoudingen waren, dat zij een biologische moeder en een sociale moeder heeft en dat zij door beiden zeer gewenst was en dat beide moeders heel veel van haar houden. De moeder had samen met de duomoeder het leven van de minderjarige vormgegeven en de rol van de duomoeder als moeder was volgens de rechtbank niet te ontkennen. De rechtbank was van oordeel dat het vastleggen van het juridisch ouderschap in het belang van de minderjarige was omdat het aansloot bij haar afstamming en haar blijk zou geven van haar ontstaansgeschiedenis. Dat er geen draagvlak bestond om te komen tot afspraken of samenwerking en dat dit mogelijk schade toe zou brengen aan de minderjarige vond de rechtbank onvoldoende doorslaggevend nu juridisch ouderschap los kan worden vastgesteld van de ex-partnerproblematiek tussen partijen. Er kan niet worden voorbijgegaan aan het recht en het belang van de minderjarige om de rol van de duomoeder in haar leven als instemmende levensgezel en primair hechtingsfiguur vast te leggen. Het feit dat er inmiddels omgang was met de biologische vader (de bekende donor) maakt dat oordeel niet anders, aldus de rechtbank.

7. Conclusie en aanbevelingen

In het geval dat de duomoeder na het verbreken van haar relatie met de geboortemoeder het kind wil erkennen, zal de weg van de vervangende toestemming moeten worden gevolgd. Zij moet aantonen dat zij de levensgezel van de geboortemoeder was, heeft ingestemd met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad en moet de toets van de belangenafweging doorstaan.

De verwekker en biologische vader met family life blijken in de rechtspraktijk redelijk verzekerd van hun vervangende toestemming, tenzij dit de belangen van de moeder bij een

²⁵ Kamerstukken II 2011/12, 33032, nr. 3, p. 13. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de wet volgen echter geen overgangsbepalingen. De wet geldt daarom ook voor nieuwe gevallen, alsook voor reeds voor 1 april 2014 bestaande rechtsfeiten.

²⁶ Deze uitspraak is te vinden onder het instemmingsvereiste, voornoemd.

ongestoorde verhouding met het kind schaadt of de evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrang is. Van deze laatste grond zal slechts in uitzonderingsgevallen sprake zijn.

Wij constateren een achterstand van de duomoeder ten opzichte van de verwekker/vader met family life gelet op alle toetsingscriteria die de duomoeder moet doorstaan. Vergelijk ook aantekening 23 van het commentaar op artikel 1:204 BW in de Groene Serie door Vonk.²⁷ Daarin geeft zij onzes inziens terecht aan dat als de instemmende levensgezel om toestemming vraagt, volgens het wettelijk systeem een ruimere mogelijkheid tot afwijzing geldt dan bij de verwekker (met of zonder band met het kind) of de biologische vader met family life. Dit zou laten zien dat het moeilijk is om sociaal, juridisch en biologisch ouderschap goed te verdelen, als de rollen uiteenlopen. De duomoeder heeft in onze visie een achterstandspositie ten opzichte van de mannelijke partner van de geboortemoeder c.q. verwekker/vader met family life. Daarbij constateren wij dat in de rechtspraak de biologische band tussen verwekker/vader met family life, kennelijk zwaarder weegt dan het sociale ouderschap. Wij zijn van mening dat de biologische band in ieder geval gelijk moet worden gesteld aan het sociale ouderschap, zo niet minder zwaar zou moeten wegen. Het gaat immers om de evenwichtige en sociale ontwikkeling van het kind, welk belang in onze optiek altijd een belang van eerste orde dient te zijn. Het zou goed zijn als er in de rechtspraak duidelijkheid komt over de vraag wat onder de "instemming met een daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad" moet worden verstaan. Legt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het begrip terecht zodanig ruim uit dat moet worden ingestemd met het geheel van handelingen gericht op het op anders dan natuurlijke wijze laten ontstaan van de zwangerschap? Of moet, in lijn met de Memorie van Toelichting bij de Wet Lesbisch ouderschap, dat moment terug te geleiden zijn naar het tijdstip van de kunstmatige bevruchting en is dat moment tot op de dag nauwkeurig aan te wijzen?

Het strekt voorts tot aanbeveling om de wettelijke belangenafweging in te perken. Die belangenafweging zou naar onze mening enkel aan de orde dienen te zijn indien er voorafgaand aan de procedure reeds sprake is van een derde-belanghebbende (verwekker/donor met of zonder family life). In de gevallen waarin een verzoek tot vervangende toestemming speelt en enkel de voormalig vrouwelijke partners hierbij zijn betrokken, gaat het vereiste dat de erkenning in het belang van het kind moet zijn onzes inziens te ver. Met name nu het ernstig verstoord zijn van de relatie een veelvoorkomende grond is om het verzoek tot vervangende toestemming af te wijzen. Dat betekent enerzijds dat de geboortemoeder de afwijzingsgrond zelf kan beïnvloeden. De verstoorde relatie mag daarom in onze ogen niet de enige

reden zijn om in het kader van de belangenafweging het verzoek tot vervangende toestemming af te wijzen.

Conform de aanbeveling van de Staatscommissie zou het eveneens wenselijk zijn dat de voorwaarde dat sprake is van een onbekende donor bij gehuwde/geregistreerde vrouwelijke partners voor het verwerven van het juridische ouderschap voor de duomoeder uit de wet verdwijnt. Ingeval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen wordt de vrouwelijke partner van de geboortemoeder automatisch juridisch ouder van het kind zoals dat nu geldt voor heteroseksuele huwelijken of geregistreerde partnerschappen. Dit geeft meer ruimte voor de vrouwelijke partners om naar eigen keuze hun kindwens en hun wens tot gezamenlijke ouderlijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Ongelijkheid naar geslacht wordt hiermee vermeden. Ook zou de wetgever de genetische moeder niet zijnde de juridische moeder een rechtsingang moeten geven om op grond van artikel 1:204 lid 3 BW ontvankelijk te zijn in haar verzoek.

Als laatste zijn wij van mening dat in de feitenrechtspraak nog altijd te veel waarde wordt gehecht aan de biologische verwantschapsband. Er zou in onze visie, gelet op de huidige gezinssamenstellingen, nog meer aandacht moeten zijn voor de positie en de belangen van de sociale ouder, waarbij uiteraard het belang van het kind niet kan worden vergeten. Gelet op de gevonden jurisprudentie is dat naar onze mening nog onvoldoende het geval waardoor de duomoeder nog altijd op achterstand staat in de erkenningsprocedure. Kortom: hier ligt wat ons betreft een taak voor de feitenrechter.

27 M.J. Vonk, in: *GS Personen- en familierecht*, artikel 1:204 BW, aant. 23 (online, bijgewerkt 20-1-2023).